

임금에 관한 최근 판결 경향의 검토

이섿별* · 권오성**

목 차

I. 서론

III. 평균임금 관련

II. 통상임금 관련

IV. 결론

I. 서론

임금은 근로자가 근로계약을 체결하는 주된 목적이며, 근로자 생존의 기초를 이루는 근로조건이다. 근로자의 노동은 성질상 보존이 어려우므로 근로자가 당장의 생활을 유지하기 위하여 궁박한 상황에서 근로계약을 체결하기도 한다. 더구나 노동은 근로자의 인격과 분리할 수 없으므로 근로자가 노동력을 거래하는 때에는 자신의 생활조건에 따른 제약이 있기 마련이다. 이처럼 상대적 약자로서 종속된 근로자의 지위는 근로자에게 불리한 여건에서 책정된 임금을 감내하도록 할 뿐 아니라, 임금이 체불된 경우 이에 적절히 대응하는 것도 곤란하게 한다. 따라서, 근로기준법 등 노동관계법령의 임금에 관한 규율은 기본적으로 임금의 최저수준을 보장하거나 임금의 지급을 보장함을 주된 내용으로 한다. 한편, 사용자가 근로자에게 지급하기로 약속한 금품이 법적으로 ‘임금’에 해당하는

DOI:<https://doi.org/10.46329/LLF.2022.07.36.141>

논문투고일자: 2022.06.22, 심사일자: 2022.07.03, 게재확정일자: 2022.07.12.

* 제1저자: 성신여자대학교 일반대학원 박사과정

** 교신저자: 성신여자대학교 법과대학 교수

가의 문제, 즉 ‘임금성’의 문제는 이러한 금품에 대하여 노동법상 보호가 적용되는가를 판단하는 전제로 기능한다.

한편, 근로기준법은 이러한 임금 개념 이외에 ‘평균임금’과 ‘통상임금’이라는 두 가지 도구적 개념을 상정하고 있다. 전자는 퇴직금 및 휴업수당, 휴업보상·장해보상·유족보상 등의 산정 기초가 되고, 후자는 해고예고수당 및 연장·야간·휴일근로수당의 산정 기초가 된다. 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하는가의 문제가 금품 지급에 대하여 노동법상 보호가 적용되는가의 판단과 관계있다면, 평균임금이나 통상임금의 산정 문제는 그 자체에 어떠한 의미가 있는 것이라기보다는 근로기준법 등에서 규정하는 제반 법정수당 산정의 전제가 된다는 점에서 도구적 성격을 갖는다. 그런데, 종래 이러한 평균임금과 통상임금의 산정방식과 관련하여 법적 분쟁이 빈번하게 발생하여 왔는바, 이러한 분쟁의 원인은 1차적으로는 근로기준법 및 동법 시행령에 규정된 이들 용어에 대한 정의, 특히 통상임금에 관한 정의가 명확하지 않은 데 있다고 생각한다. 나아가, 종래 법원의 일부 판결에서 평균임금 산정 시 반영해야 하는 ‘임금’의 판단 시 근로기준법이 규정하지 않은 추가적인 요건을 요구하거나, 통상임금의 산정 시 법문이 명시하지 않은 ‘고정성’이라는 요소를 통상임금의 개념표지로 요구한 것도 이들 개념에 대한 이해를 어렵게 한 원인이 되었다고 생각된다.

이러한 상황에서 최근 통상임금과 평균임금의 개념에 관하여 종래와는 다소 다른 입장에 선 것으로 평가되는 판결들이 선고되었다. 이에 이 글에서는 이러한 판결들을 소재로 통상임금과 평균임금의 개념에 관한 새로운 해석론의 가능성을 모색해 보고자 한다.

Ⅱ. 통상임금 관련

1. 통상임금 요건을 둘러싼 견해들

(1) 통상임금 정의 규정 및 역할

통상임금은 근로자에게 지급할 ‘가산수당’의 산정을 위한 개념이다. 1953년 제정 근로기준법 제46조는 “사용자는 연장시간근로와 야간근로에 대해서 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다.”라고 규정하고 있었다. 제정 근로기준법에서 통상임금은 ‘가산임금’의 산정을 위한 기능만을 담당했다. 이후 1961년 개정 근로기준법에서는 ① 근로자 평균임금이 통상임금보다 저액일 경우 통상임금액을 평균임금으로 하는 ‘평균임금의 최저한도’(동법 제19조) 역할을 하게 되었으며, ② 해고예고수당(동법 제27조의2 제1항) 및 ③ 연차유급휴가수당(동법 제48조 제2항, 제3항)을 계산할 때 통상임금이 기준이 되었다. 이처럼 통상임금의 기능이 확대되어 왔지만, 근로기준법은 법률의 수준에서 통상임금의 정의규정을 마련하고 있지는 않다.

(2) 통상임금의 판단기준에 관한 판례법리

판례는 통상임금의 개념에 관하여 근로기준법 시행령 제6조에서 규정하는 정기성, 일률성이라는 개념표지 이외 ‘고정성’이라는 표지를 추가로 요구하고 있다. 2013년 대법원 전원합의체 판결¹⁾이 선고되기 전부터 대법원은 근로기준법 시행령 제6조에서 정하는 통상임금의 요건을 “어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것이 정기적, 일률적으로 지급되는 고정적인 임금”이라고 판시해 왔다.²⁾ 따라서 실제 근무

1) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결.

2) 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결, 대법원 2007. 6. 15. 선고 2006다13070 판결 등.

성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 임금은 ‘고정성이 없어’ 통상임금이 아니라고 하였다. 당시 대법원은 시행령이 명시적으로 규정하지 않은 ‘고정적’이라는 요건을 추가하기는 했지만, 고정성에 대한 명확한 해석 기준은 따로 두지 않았다. 다만 법원은 시행령의 ‘일률성’을 “모든 근로자’에게 지급되는 것뿐만 아니라 ‘일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자’에게 지급되는 것도 포함”되는 것이라는 견해를 취하였고, 이에 더하여 “‘일정한 조건’이란 ‘고정적이고 평균적인 임금’을 산출하려는 통상임금의 개념에 비추어 볼 때 ‘고정적인 조건’”이라고 판시하였다.

2013년 대법원 전원합의체 판결은 통상임금의 ‘고정성’ 요건을 따로 떼어 구체적으로 판단한 최초의 판결이다. 해당 판결에서 통상임금 판단기준으로서 ‘고정성’을 “근로자가 제공한 근로에 대하여 업적, 성과 기타의 추가적인 조건과 관계없이 당연히 지급될 것이 확정되어 있는 성질”이라고 판시하고, 나아가 고정적인 임금이란 “임금의 명칭 여부를 불문하고 임의의 날에 소정근로시간을 근무한 근로자가 그다음 날 퇴직한다고 하더라도 그 하루의 근로에 대한 대가로 당연히하고도 확정적으로 받게 되는 최소한의 임금”이라고 판시하였다.

2013년 전원합의체 이후 대법원은 통상임금 해당 여부를 정기성, 일률성, 고정성이라는 세 가지 요건으로 판단하고 있다.

(3) 통상임금의 개념에 관한 학설들

통상임금의 개념표지로 ‘고정성’을 요구하는 판례에 대하여 찬반의 양론이 제시되어왔다. 먼저, ‘고정성’을 긍정하는 견해는 통상임금은 반드시 사전에 확정되어야 한다는 성질에 주목한다. 즉, 통상임금은 ‘사전확정성’이 핵심이므로 ‘고정성’ 요건은 통상임금과 떼어 수 없는 관계라는 입장이다. 대법원에서 말하는 ‘고정성’은 이러한 통상임금의 성질을 재확인했을 뿐이라는 관점이다. 통상임금이 ‘사전확정성’을 가

져야 하는 이유는 통상임금은 근로자의 근로가치를 미리 정해놓은 것이기 때문이라는 견해가 있다.³⁾ 근로자의 입장에서 연장·야간·휴일근로를 하기에 앞서 이러한 근로에 대한 수당을 계산할 수 있기 위해서는 근로자의 근로가치를 미리 산정해 놓는 것이 필요하다는 입장이다. 연장·야간·휴일근로는 근로자가 평소보다 열악한 상황에서 근로를 제공하는 것이다. 그래서 그에 따른 수당은 가산해서 지급하는 것이고, 가산수당이 적절한 수준인지 판단하기 위해서는 근로자의 근로가치가 제대로 평가되는 게 중요하다는 견해이다. 따라서 근로 가치가 왜곡되지 않기 위해선 임금은 사전에 정해져 있어야 하고, ‘사전확정성’을 판단하는 기준으로서 통상임금의 ‘고정성’ 요건이 필요한단 입장이다. 이 견해는 통상임금은 가산수당의 역할 말고도 ‘평균임금의 최저한도’로 기능하는 역할도 하므로 ‘고정성’이 필요하다고 주장한다.⁴⁾ 한편, 근로기준법 제2조 제2항은 평균임금이 통상임금보다 적으면 통상임금액을 평균임금으로 한다고 규정하는데, 이러한 견해는 통상임금이 평균임금의 최저한도 역할을 하는 까닭은 통상임금은 사후가변적으로 변할 수 있는 평균임금의 부작용을 대처하기 위한 기능을 한다고 말한다. 따라서 이러한 법조문에 비추어 보면 통상임금엔 ‘고정성’ 요건이 필수적이라고 주장한다.

반면, 근로기준법령이 명시적으로 규정하지 않은 ‘고정성’을 통상임금의 개념표지로 요구하는 것은 타당하지 않다는 반론도 있다. 현재 대법원이 정의하는 통상임금의 ‘고정성’ 요건의 의미가 달라져야 한다고 주장하는 견해들이다. 먼저, 대법원에서 말하는 ‘일률성’과 ‘고정성’ 요건을 충족했는지 명확하지 않은 경우에도 통상임금에 포함될 수 있는 여지를 남긴다는 견해가 있다.⁵⁾ 이 견해는 통상임금 개념요

3) 권혁, “통상임금의 ‘고정성’에 관한 법리 재평가”, 「노동법논총」 제28집, 한국비교노동법학회, 2013. 8. 259면.

4) 위의 글, 261면.

5) 이철수, “통상임금에 관한 최근 판결의 동향과 쟁점 - 고정성의 딜레마-”, 「서울대

소 중 지급형태에 관한 부분도 있지만, ‘소정근로의 대상’이라는 실질적 개념 지표가 포함된다고 본다. 따라서 ‘일률성’과 ‘고정성’이라는 지급형태에 관한 요소에만 천착하면 실질적 지표인 ‘소정근로의 대가’라는 부분을 놓칠 수 있음을 경계해야 한다고 주장한다. 이 주장은 근로자의 소정근로가 이행되는 경우를 예상하고 사전에 지급조건과 지급액이 확정되어 있다면 ‘고정적’이라고 설명한다.⁶⁾

한편, 정기적으로 일정한 주기에 따라 지급되는 임금을 정해놓은 것으로도 그 임금은 ‘사전확정성’ 및 ‘소정근로의 대가’라고 주장하는 견해도 있다.⁷⁾ 불시에 발생할지 모르는 사정을 조건으로 추가하여 통상임금성을 부인하는 것은 통상임금의 범위를 부당하게 좁히는 결과를 초래한다는 입장이다. 특히, 임금 지급에 관한 조건을 추가하는 매우 간단한 방식으로 소정근로의 대가에 해당하는 임금의 통상임금성을 부정하는 것은 통상임금의 강행성을 훼손하는 것이라고 주장한다.

살펴본 것처럼 통상임금을 둘러싼 다양한 해석들이 존재한다. 이는 근로기준법상 통상임금 정의에 관한 규정은 없고, 대법원은 근로기준법 시행령에서 정하는 요건 이외 ‘고정성’을 통상임금 요건으로 삼기 때문이다.

한편, 최근 논의 중 하나로 통상임금 성격을 두 가지로 해석해야 한다는 견해도 있다. 이는 통상임금이 ① 본래 목적인 가산수당 계산을 위한 ‘도구적 개념’으로 작용하는 경우와 ② 연차휴가나 육아휴직 등 휴가 기간의 ‘기준임금’으로 작용하는 경우를 달리 보아야 한다는 입장이다.⁸⁾ 이 견해는 통상임금의 기본적인 목적을 ‘가산임금의 계산’으로

학교법학」 제54집제3호, 서울대학교 법학연구소, 2013. 9. 897면

6) 위의 글, 903면.

7) 김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 「노동법학」 제71호, 한국노동법학회, 2019. 9. 113면.

8) 방강수, “통상임금 법리의 이원화”, 「법학논총」 제36권제4호, 한양대학교법학연구소, 2019, 274면.

보고, 이를 위해서는 임금을 시간 단위로 쪼개야 하므로 통상임금은 본질이 ‘시간급’이라고 설명한다.⁹⁾ 반면 해고예고수당, 연차휴가수당 및 출산휴가급여 등은 ‘시간급’을 도출해내는 것보다는 ‘1일 단위’의 임금을 산정하는 것이 각 수당의 취지에 부합한다고 주장한다. 따라서 통상임금 성격을 가산수당을 계산하는 경우와 가산수당 이외 수당을 계산하는 경우로 나누어 고찰해야 한다는 것이다. 또한, 이 견해는 ‘통상임금 범위’도 양자의 경우에서 달리 보아야 한다고 주장한다. 가산수당 계산을 위한 통상임금은 지급 당시 그 범위가 사전에 확정되어야 하므로 ‘고정성’ 요건이 필요하나, 가산수당 계산 이외 수당에선 그럴 필요가 없어 ‘고정성’을 요구하지 않는다는 입장이다.¹⁰⁾ 그런데, 이처럼 통상임금의 개념과 범위를 이원화하자는 입장은 대법원이 통상임금에 요구하는 ‘고정성’ 요건을 비판 없이 수용한 결과라고 생각한다. 통상임금을 근로기준법 시행령의 법문대로 ‘정기적·일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정해진’ 임금이라는 문언 그대로 해석한다면 굳이 통상임금 법리를 이원화할 필요는 없다고 생각한다. 즉, 가산수당 이외의 수당에 대해서만 ‘고정성’ 요건을 배제하는 방식으로 통상임금 체계를 이원화할 것이 아니라, 통상임금의 산정이 문제되는 모든 국면에서 ‘고정성’ 요건을 배제하는 방식으로 일원적으로 해석하는 해석론을 모색하는 것이 우선되어야 한다고 생각한다.

(4) 기존 견해들에 대한 검토

근로계약의 임금은 기본적으로 후급(後給)이다. 근로계약의 체결 당시에는 근로계약의 당사자들은 근로자가 실제로 어느 정도의 시간을 근로할 것인가를 확정하기 어렵다. 그래서 소정근로시간을 정하고, 이러한 소정근로시간에 대한 임금을 잠정적으로 정하게 된다. 이러한

9) 위의 글, 275면.

10) 위의 글, 263면.

소정근로시간에 대하여 지급하기로 ‘정한’ 임금액이 통상임금의 본질이라고 생각한다. 따라서 근로계약 체결 당시 사용자와 근로자가 정한 근로시간, 즉 소정근로시간 이외에 추가적으로 제공된 근로에 대하여 지급되는 임금, 즉 소정 외 임금은 당연히 통상임금에서 제외된다. 한편, 근로자가 근로자의 귀책사유로 소정근로를 모두 이행하지 못한 경우(결근, 지각 등)에는 근로계약의 이행상의 건련성에 근거하여 임금액을 공제하게 될 뿐, 이러한 사정을 이유로 통상임금이 감액되는 것은 아니다. 오히려 통상임금을 기준으로 공제할 금액을 산정하여야 한다.

최근 대법원은 정기상여금을 근로자의 퇴직일이 속한 달에 퇴직일까지 일할계산하여 지급하기로 한 경우, 그러한 정기상여금은 통상임금에 해당한다고 판시하였다.¹¹⁾ 이 사안에서 연간 정기상여금은 약정 통상급의 600% 수준으로 정해져 있었고, 회사는 취업규칙에 따라 이를 2개월마다 약정 통상급의 100%씩 지급하고 있었다. 또한 취업규칙에는 ‘입사 또는 퇴직한 날이 속하는 월의 임금은 일할계산한다.’라는 규정도 포함되어 있었다. 법원은 “단체협약 등에서 정기상여금을 특정 시점에 재직 중인 근로자만 지급한다는 규정을 둔 경우에도, 그 규정만을 근거로 이미 근로를 제공했더라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 정기상여금을 전혀 지급하지 않는 취지라고 단정할 것은 아니다. 특정 시점 전에 퇴직하더라도 이미 근무한 기간에 비례하는 만큼 정기상여금을 지급해야 하는지는 단체협약 등에서 정기상여금을 근무 기간에 비례하여 지급한다는 규정을 두고 있는지 아닌지만 아니라, 정기상여금의 지급 실태나 관행, 노사의 인식, 정기상여금 그 밖의 임금 지급에 관한 규정 등을 종합하여 구체적인 사안에서 개별적으로 판단해야 한다.”라고 하면서, “이런 내용과 취지를 고려할 때, 정기상여금의 ‘전액’ 지급은 현재 재직 중인 사람에게 지급한다는

11) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2019다238053 판결.

의미이고, 정기상여금 지급 전 퇴직한 사람에게는 이미 근무한 기간에 해당하는 것도 지급하지 않는다는 의미로 보기는 어렵다.”라고 판단하였다. 즉, 정기상여금이 퇴직자에게 퇴직일까지 일할계산하여 지급될 때, 그 정기상여금은 ‘고정성’ 요건을 결하고 있지 않으므로 통상임금에 해당한다고 보고 있다.

위 판결에서 대법원은 여전히 ‘고정성’ 요건을 토대로 정기상여금의 통상임금성을 판단하고 있다. 위와 같은 사안에서 정기상여금을 통상임금에서 제외하려면, 취업규칙에서 퇴직일이 속한 달은 급여를 일할계산한다는 규정을 삭제하면 그만이다. 임금 지급 방식에 따라 무엇이 시간의 가치인지 결정하게 되는 본말이 전도되는 현상이 일어나게 되는 것이다.

2. 재직 조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성

(1) 대법원의 판단

대법원은 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 이래 재직 조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 줄곧 부정해왔다. 해당 판결은 어떤 금품의 통상임금성이 인정되려면 ‘고정성’이 인정되어야 한다는 통상임금의 요건을 재확인하였다. 따라서 특정 시점에 ‘재직하는 자’에게만 지급한다는 조건이 붙은 임금은 그 조건을 달성한 자에게만 지급되는 것이므로 소정 근로에 대한 대가성도 없고, 특정 시점에 조건 성취 여부도 불확실하여 ‘고정성’도 부정되므로 통상임금에 해당하지 않는다고 판시하였다. 해당 판결의 해석은 통상임금의 범위를 부당하게 좁힌다고 하여 많은 비판을 받았다.

(2) 최근 하급심의 판단

최근 하급심 판결에는 재직 조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성

을 인정한 사례들이 있는바, 이러한 판결들은 크게 ‘고정성’에 관한 판단 없이 정기상여금의 통상임금성을 인정하는 유형과 기존의 ‘고정성’의 토대 위에서 정기상여금의 통상임금성을 긍정한 유형으로 나누어 볼 수 있다.

전자의 대표적인 예로 서울고등법원 2018. 12. 18. 선고 2017나 2025282 판결을 들 수 있다. 해당 판결에서 ‘정기상여금’은 근로의 대가에 해당하며 지급 기간이 수개월 단위인 경우에도 이를 누적하여 후급으로 지급하는 것에 불과 하다고 하였다. ‘재직 조건’은 이같이 이미 발생이 약정된 임금을 부지급하는 조건으로서 그 유효성을 인정할 수 없다고 판시하였다. 해당 판결에서는 재직 조건이 붙은 정기상여금이 ‘고정성’을 충족하는지 따로 판단하지 않는다. 하지만 판결에서는 정기상여금이 ‘상여’라는 명칭을 사용하고 있다 하더라도 “고정적 금액이 계속적·정기적으로 지급되는 형태의 정기상여금은 더 이상 본래 의미의 ‘상여’로서의 성질을 가지고 있지 아니하며, 오히려 근로자의 입장에서는 기본급과 마찬가지로 근로를 제공하기만 하면 그에 대한 기본적인 확정적인 대가로서 당연히 수령을 기대하는 임금에 해당”한다고 판단하였다. 즉, 재직 조건이 붙은 정기상여금은 기본급과 다르게 보아야 할 이유가 없다고 판시하였다.

후자의 예로는 서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2016나2032917 판결이 있다. 해당 판결에서 ‘정기상여금’은 근로 제공과 관계없이 지급일에 재직하는 ‘재직의 대가’가 아닌 ‘소정 근로의 대가’라고 보았다. 이 사건 상여금은 신규 입사자의 경우, 경력과 근속기간에 따라 지급률이 달랐고, 복직이나 휴직하는 근로자에게는 일할계산, 결근자에게는 일할 감액 되어 지급되었기 때문이다. 다만 앞선 판례와 달리 ‘재직 조건’의 효력은 인정하였다. 해당 판결에선 원칙적으로 근로조건은 근로자와 사용자가 자유의사에 따라 결정할 수 있다고 보았다. 무엇보다 해당 판결은 분할지급 된 정기상여금은 그 성격이 선불인지 후불인지 명확하지 않다고 해석한다. ‘재직 조건’이 근로자에게 미리 발

생한 임금을 포기하게 할 수도 있지만, 미리 받은 임금을 반환하지 않는 이익도 생길 수 있다고 말한다. 따라서 ‘재직 조건’은 근로자 또는 사용자에게 일방적으로 불리하거나 유리하다고 단정할 수 없다고 판시한다. 나아가 해당 판결에서는 재직 조건이 붙은 정기상여금의 ‘고정성’도 인정하였다. 이 사건 상여금은 연간 지급액이 월 기본급의 800%로 확정되어 있고, 그 지급액은 소정 근로의 대가이므로 추가적인 조건 성취 여부와 관계없이 당연히 지급되는 임금이라고 판시하였다. ‘통상’의 사전적 의미는 ‘특별하지 않고 예사로 있는 일’을 의미하고 ‘퇴직’은 근로자 재직 중 발생하지 않는다는 점, 휴직자·복직자·징계대상자 등 근로자 개인적 특수성을 고려해 지급을 제한하는 임금이라도 정상적인 근로관계를 유지하는 근로자에 대한 임금 지급의 ‘일률성’이 부정되지 않는 점을 비추어 보면 ‘재직 조건’이 있다고 하더라도 정상적인 근로관계를 유지하는 근로자에 대하여는 그 임금 지급의 고정성을 부정할 것은 아니라고 판시하였다.¹²⁾

(3) 판결에 대한 검토

이러한 하급심 판결 동향에 따라 판결에서 정하는 통상임금의 고정성 요건을 사전확정성으로 해석할 게 아니고 사전결정성 정도로 해석해야 한다는 견해가 있다.¹³⁾ 특정한 임금계산 주기에 대하여 실제로 지급되는 임금은 그 사후적 성격상 실제 근로시간에 따라 가변적일 수밖에 없다. 그러나 대법원이 정하는 ‘고정성’ 요건에 따르면, 임

12) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결은 단체협약이나 취업규칙 등에 휴직자나 복직자 또는 징계대상자 등에 대하여 특정 임금에 대한 지급 제한 사유를 규정하고 있다 하더라도, 이는 해당 근로자의 개인적인 특수성을 고려하여 그 임금 지급을 제한하고 있는 것에 불과하므로, 그러한 사정을 들어 정상적인 근로관계를 유지하는 근로자에 대하여 그 임금 지급의 일률성을 부정할 것은 아니라고 판시하였다.

13) 임상민, “재직 조건부 정기상여금의 통상 임금성”, 『노동법연구』 제51호, 서울대학교노동법연구회, 2021. 9, 302면.

금 지급 여부나 지급액이 사전에 확정될 것을 요구한다. 따라서 ‘채직 조건’이 붙은 정기상여금은 사전확정성이 없다고 보아 통상임금성을 부정하는 것이다. 위 견해는 대법원이 말하는 사전확정성은 ‘사후 가변성’을 봉쇄하기 때문에 필연적으로 가변적인 속성을 지니는 임금은 무엇이든 통상임금에서 배제할 수 있는 위험성을 지적한다. 나아가 2013년 전원합의체 판결의 “휴직자나 복직자, 징계대상자 등에게 특정 임금에 대한 지급 사유를 제한하더라도 개인적인 특수성을 고려해 임금 지급을 제한한 것에 불과하므로 이 같은 사정이 임금 지급의 ‘일률성’을 부정할 사유는 아니다.”라는 논리에 터 잡아 퇴직이야말로 고정성 및 통상임금성에 지장을 초래하지 않는 개인적인 특수성으로 평가되어야 한다고 주장한다.¹⁴⁾

‘채직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 두고 법원들 사이에서도 다른 판단이 나오는 이유는 통상임금 요건에 대한 해석론이 제대로 정착되지 않았기 때문이라고 생각한다. 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 통상임금의 ‘일률성’과 ‘고정성’ 요건을 재정립할 필요가 있다. ‘일률성’은 소정근로시간과 그에 따른 급여로부터 도출되는 일정한 비율이란 뜻으로 해석할 필요가 있고, ‘고정성’은 당사자 사이에 임금산정방법이 사전에 정해져 있다는 정도의 의미로 이해할 필요가 있다.

3. 도급근로자의 통상임금 산정

(1) 근로기준법 제47조의 ‘도급근로자’의 의미

2022년 3월 대법원은 실적에 따라 수수료를 받는 코웨이 수리기사들의 근로자성을 인정¹⁵⁾했다. 더불어 이들이 사용자 측에게 청구한

14) 위의 글, 303면.

15) 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021다302155 판결.

주휴수당·연차휴가 수당 청구를 인용하면서 ‘설치·수리기사들이 받은 수수료는 통상임금’에 해당한다고 판시하였다. 이 판결에서 대법원은 그동안 ‘특수고용직’으로 분류되었던 생활가전제품 설치·수리기사들의 근로기준법상 근로자성을 인정했다. 나아가 이들이 실적을 기준으로 받았던 ‘수수료’를 통상임금으로 인정하였다. 위 판결의 원심인 서울고등법원 2021. 10. 26. 선고 2019나2031229판결은 원고 수리기사들이 “근로의 대가인 임금을 근로시간에 따라 받은 것이 아니라 근로시간과 무관하게 실적을 기준으로 책정된 수당을 합쳐 매월 받으며, 원고들은 피고에게 도급제로 근로 제공을 한 것으로 보이므로 근로기준법 제47조에서 정한 도급근로자에 해당”한다고 판시하였다. 대법원도 이런 입장을 그대로 수용하였다. 따라서 원심판결은 근로기준법 시행령 제6조 제2항 제6호에서 정하는 ‘도급 금액으로 정한 임금의 통상임금 산정방식’에 따라 원고들의 통상시급을 계산하여 주휴수당 및 연차휴가 수당을 계산하였다. 원심판결의 법리가 대법원에서 확정됨에 따라 좀처럼 논의되지 않았던 근로기준법 제47조의 ‘도급근로자’에 대한 관심이 높아지고 있다.

근로기준법 제47조 ‘도급근로자’의 의미에 관하여 노무 수행자가 근로기준법상 근로자성이 인정되고, 실적급제 보수를 받고 있다면 곧바로 ‘도급근로자’로 인정할 수 있다는 견해가 있다.¹⁶⁾ 이러한 견해가 드는 대표적 예는 ‘플랫폼 노동자’다. 플랫폼 노동자는 플랫폼 기업에 업무 절차나 수행에 관한 지시·감독을 받고, 건당 수수료를 받는다. 이와 같은 근무 형태가 앞서 살펴본 정수기 수리기사와 같은 특수고용직과 비슷해 플랫폼 노동자도 ‘도급근로자’에 포함하는 듯하다. 나아가 위 견해는 ‘플랫폼 노동자’가 받는 건당 수수료는 근로시간 아닌 실적·성과·생산고 등의 비율로 임금이기는 하나 도급임금은 근로시간과 무관하다고 볼 수 없다고 주장한다.¹⁷⁾ 플랫폼 노동자의 근로시간

16) 방강수, “도급제 임금에서의 통상임금 법리”, 「노동법연구」 제51호, 서울대학교노동법연구회, 2021, 169면.

이 길어질수록 실적은 그에 비례해서 올라가기 때문이다. 도급제 임금은 본래가 실적급이기 때문에 ‘근로시간과 친하지는 않지만, 근로시간과 무관하지 않다.’며 근거로 근로기준법 시행령 제6조 제2항 6호를 든다.¹⁸⁾ 위 시행령은 도급제 임금을 구할 때, 도급제로 계산된 금액 총액을 ‘총 근로시간 수’로 나눠야 한다 정하고 있다. 도급제 근로자의 통상임금을 구하는 ‘총 근로시간 수’는 근로자가 실제로 근로한 시간으로 계산하여야 한다고 주장한다.¹⁹⁾ 디지털 기술의 발달로 사후 ‘실제 근로시간’을 산정하는 것은 어렵지 않으니 ‘도급제로 계산된 금액 총액/실제 근로시간’을 산정한 값을 통상임금으로 보아야 한다고 말한다. 따라서 도급제 근로자의 통상임금은 특성상 사후적·산술적 개념이라고 한다. 이는 통상임금은 미리 정해져 있을 것 전제하는 ‘사전적 개념’이라는 기존 견해들과는 배치되는 주장이기도 하다.

하지만 이러한 주장은 ‘도급근로자’의 범위를 무리하게 확대한 결과, 통상임금 원칙에 불필요한 예외를 만든다고 생각한다. 위 견해는 도급제 임금에서 ‘시간’이 갖는 의미를 간과하고 있다고 생각한다. 지금까지의 판결들을 살펴보면 법원은 도급근로자의 통상임금 계산 시 ‘정해져 있는 근로시간’을 중요하게 다루고 있다. 정수기 기사들이 사용자 측을 상대로 주휴수당 및 연차휴가 수당 등을 청구한 사안²⁰⁾에서 법원은 원고의 주장을 인용하며 도급제 임금에서의 ‘총 근로시간 수’를 판단하는 기준도 판시하였다. 위 판결은 ① 피고 취업규칙에 근로자는 1주 40시간을, 1일 8시간을 근무하고 외근 등으로 인한 사유로 근로시간 산정이 어려울 때 1일 8시간을 근무한 것으로 보고 있는 점, ② 피고는 용역 기사들에게 일일 근무시간 8시간, 일일 처리건수 12~15건을 권장하고 있는 점, ③ 피고가 원고들에게 고객들이

17) 위의 글, 175면.

18) 위의 글, 173면.

19) 위의 글, 185면.

20) 울산지방법원 2020. 2. 19 선고 2018가합24567 판결.

원하는 방문시간을 준수하도록 함에 따라 용역 기사들은 대체로 8시 30분경 또는 그 이전에 출근하거나 퇴근은 적어도 16시 이후에나 가능했고, 당 초 배정된 업무를 일찍 마치더라도 당일 접수된 정수기의 수리나 설치 요청 등으로 인해 16시보다 더 늦게 퇴근한 적도 많은 점 등을 비추어 보아 1일 근로시간을 8시간으로 설정하고, 통상임금을 계산하였다.

앞서 언급한 코웨이 수리기사들의 청구를 인용한 서울고등법원의 판결도 마찬가지다. 대상 판결에서는 도급제 임금의 ‘총 근로시간 수’를 산정하면서 ① 원고들이 조회나 교육 참석, 서비스대금의 납부, 업무수행에 필요한 부품의 수령 등을 위해 평일 7시 30분, 토요일 8시에 매일 소속 지점에 출근해야 했던 점, ② 피고는 콜센터를 통해 원고들에게 평일 9시부터 20시까지, 토요일 9시부터 18시까지 업무 배정을 했던 점, ③ 원고들이 예정 근무시간에 근무함을 전제로 업무배정이 이루어지고, 원고들의 실제 업무가 그 전에 끝나더라도 원고들이 대부분 배정, 이관 등에 의한 업무에 대비하여 대기하였던 점 등을 들어 이 사건 원고들의 근로시간은 평일 7시 30분부터 20시까지, 토요일 8시부터 18시까지로 보고, 통상임금을 계산하였다.

이와 같은 판시에 비추어 보면 도급근로자의 통상임금을 산정할 때, ‘약정’된 근로시간은 필수적이다. 따라서 노무 제공자가 근로기준법상 근로자에 해당하고, 실적급을 받고, 나아가 사후 근로시간을 ‘측정’할 수 있다고 하여 선불리 ‘도급근로자’로 포섭할 수는 없다고 생각한다. 무엇보다 근로기준법 시행령 제6조 제1항에서 말하는 ‘통상임금’이란 ‘근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 도급 금액’이다. 도급 금액의 통상임금 산정엔 ‘해당 임금 산정 기간의 총 근로시간 수’가 필요하다. 도급근로자가 받는 최종적인 급여액은 그가 수행한 업무 실적에 따라 사후 확정된다. 그런 특성과는 별개로 법문에 따르면 도급근로자의 통상임금은 다른 시급제 근로자와 마찬가지로 ‘미리 정해진’ 조건이어야 한다.

통상임금을 산정하기 위해선 반드시 미리 정해진 근로시간이 필요하다. 도급제 임금은 시간과 매우 친밀한 관계이다. 근로기준법 제47조에서 정하는 ‘도급’의 의미를 무리하게 확장 해석하면 임금 원칙에 연달아 예외를 낳게 된다. 통상임금이 도급제 임금에 국한하여 ‘사후적’ 성격을 가진다든가, ‘통상임금 삼원화’라든가 하는 예외가 자꾸 등장할 수 있다. 따라서 도급제 근로자의 통상임금 원칙을 논하기 이전에 반드시 근로기준법상 ‘도급’의 의미를 명확히 해야 할 것이다.

앞서 말한 대로 사전에 소정근로시간을 미리 정하지 않은 형태로 일하는 ‘플랫폼 노동자’들은 근로기준법 제47조의 ‘도급근로자’로 포섭하기 어렵다고 생각한다. 소정근로시간이 없는 것은 현행 근로기준법이 예정하지 않은 근무 형태이다. 대부분의 플랫폼 노동자들은 ‘건별 보수(piece rate)’로 임금을 받고 있다. 이 건당 가격은 실시간으로 변동되는 특성도 가지고 있다. 따라서 이들에 대해서는 영국처럼 ‘공정단가제(fair piece rate system)’를 도입하여 임금 수준을 보호해야 한다는 주장도 있다.²¹⁾

이러한 특수성을 고려하면, 플랫폼 노동자의 통상임금을 구하기 위한 산식을 생각하기 이전에 소정근로시간이 정해지지도 않은 자들의 통상임금을 구태여 구해야 하는 실익이 무엇인지를 먼저 고려해야 한다. 플랫폼 노동자들에게 추가 근로나 연차수당 등을 구하기 위한 통상임금을 계산하고 적용하는 문제보다는 이들의 최저보수를 정하는 문제가 더 시급하다고 생각한다.

(2) 근로시간의 정함이 없는 ‘플랫폼 노동자’의 임금수준 보장 방안

코로나 팬데믹 이후, 비대면 서비스 선호로 인해 플랫폼 이용이

21) 권오성, “플랫폼 노동자 최저보수 보장방안”, 「플랫폼 노동자 적정소득 보장방안 공개토론회 자료집」, 한국노동사회연구소, 2022. 3, 18면.

늘었다. 이와 비례해 플랫폼 노동자도 급증했다. 2021년 8-9월, 플랫폼 노동자는 약 220만 규모로 집계되었다.²²⁾ 이는 그 이전 10개월 대비 약 40만 명이 늘어난 수치라고 한다. 플랫폼 노동은 코로나로 인해 직장을 잃거나 생업 유지가 어려운 사람들의 대안이 되기도 했다. 그에 따라 노동법 사각지대에 있는 이들의 처우 문제가 대두되기 시작하였다.

처우에 관한 문제 중 하나는 ‘플랫폼 노동자들이 받는 임금 수준은 적정한가’이다. 이들이 받는 실수령 임금에 실제 근로시간을 나눠 보면 올해 연도 최저임금에 미치지 못한다는 주장이 있다.²³⁾ 사용자로부터 업무수행에 관한 부분을 지시·감독받는 플랫폼 노동자의 경우, 근로기준법상 근로자성이 인정될 여지가 충분하다. 이 경우 이들의 보수 수준이 해당 연도 최저임금 이상으로 보장되어야 할 것이다.

Ⅲ. 평균임금 관련

1. 경영성과급을 중심으로 한 임금성 논쟁

(1) 경영성과급의 임금성 논쟁과 대법원 판단

매년 경영 실적에 따라 지급되는 대기업 경영성과급은 뜨겁고 논쟁적 이슈이다. 1년간의 경영실적이 평가되고 이를 바탕으로 연말연시에 경영성과급이 지급된다. 이 시기 기업은 몸살을 앓는다. 노사 간 경영성과급을 둘러싼 ‘공정성’ 문제가 매년 대두되기 때문이다. 이는

22) 정진호, “플랫폼 노동자 220만명으로 늘었다..평균월급 192만원”, 중앙일보, 2021. 11. 18자 인터넷판, <<https://www.joongang.co.kr/article/25024839#home>>, (2022. 6. 21 최종방문).

23) 나주예, “플랫폼 노동자 실수령 월 125만원..최저임금의 65% 불과”, 한국일보, 2022. 3. 31자 인터넷판, <<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022033114100004382>>, (2022. 6. 21 최종방문).

단순히 문제 제기에 그치지 않았다. 경영성과급 논쟁은 대기업 사무직 노동조합 결성을 촉발²⁴⁾하기도 했다. 기업 내부 근로자들의 불만이 극에 달하자 SK 그룹의 회장은 연봉을 자진 반납하겠다는 의사²⁵⁾를 밝혔다. 경영성과급에 대한 논란은 사회적 이슈로 끝나지 않고 법적 분쟁으로 이어졌다. 근로자들은 경영성과급이 평균임금이기 때문에 퇴직금에 포함되어야 한다고 주장하며 회사를 상대로 소송을 제기했다. 2022년 4월 현재, 법원의 판결을 기다리는 기업들은 삼성전자, SK 하이닉스, LG디스플레이, 삼성디스플레이, 삼성카드 등이다. 이런 사태들로 미루어보면 경영성과급 논쟁은 현재 기업에서 가장 뜨거운 문제라고 해도 과언이 아니다. 근로자들은 경영성과급에 대한 권리를 사 측에게 요구한다. 기업은 근로자들의 사기 저하나 이탈을 막기 위하여 경영성과급 지급기준을 다시금 타협하거나 설득을 시도한다. 이런 상황을 놓고 보면, 노사 양측 모두 경영성과급이 ‘근로의 대가’에 해당한다고 암묵적으로 인지하는 것처럼 보인다.

하지만 법원의 판단은 엇갈린다. 최근 하급심 판결에 따라 ‘엇갈린다’라는 표현을 쓰는 것이고, 법원은 그동안 줄곧 경영성과급의 임금성을 부정해온 입장이다. 대법원²⁶⁾은 현대미포조선 사례에서 상여금의 임금성 기준에 대해 판시하였다. “상여금이 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지나, 그 지급 사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것은 임금이라고 볼 수 없으며, 또한 그 상여금이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 산입될 수 있는지는 특별한 사정

24) 권희원, “성과급 불만 폭발한 ‘MZ세대’...사무직 노조 결성 속도”, 연합뉴스, 2021. 4. 12. 자 인터넷판. <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210412124500003?input=1195m>>.

25) 주성호, “최태원 연봉 반납까지 나왔던 SK 성과급 논란 '일단락'”, 뉴스원, 2021. 2. 4. 자 인터넷판, <<https://www.news1.kr/articles/?4203565>> (2022. 6. 10. 최종 방문).

26) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다54322 판결.

이 없는 한 퇴직 당시를 기준으로 판단하여야 한다.”고 보았다. 그러면서 피고 현대미포조선의 경영성과급은 ① 1992년도부터 원고들이 모두 퇴직한 1998년도까지의 기간 동안에는 성과급의 지급기준이 거의 매년 틀려 그 지급액이 확정되어 있었다고 보기 어렵고, ② 성과급 지급조건에 ‘무쟁의 내지 무분규’가 포함되어 있어 분규 발생 시 회사가 성과급을 계속 지급할 의사가 있다거나 그와 같은 관행이 성립되었다고 보기 어렵다는 점을 들어 경영성과급은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당하지 아니한다고 보았다. 즉, 판례는 ① 계속적·정기적으로 지급되고 ② 지급액이 확정되어 있다면 그 금품은 ‘근로의 대가성’이 있다고 판단하였다. 경영성과급은 일시적으로 지급되는 것에 불과하고, 경영성과급 지급기준을 세울 당시에는 기업의 경영 목표달성 여부가 불확실하여 성과급이 지급될지 모르기 때문에 임금을 줄곧 부정해왔다.

(2) 경영성과급의 임금성을 부정하는 견해들

1) ‘지급의무 확정성’을 결한다고 보는 관점

경영성과급의 임금성이 문제가 되는 경우는 주로 퇴직금 관련 분쟁이다. 즉, 경영성과급이 퇴직금 산정 기초가 되는 ‘평균임금’에 포함되는지가 문제 된다. 판례는 평균임금은 “사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, 근로자에게 ① 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 ② 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면, 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함된다.”고 판시하였다.²⁷⁾ 판례는 평균임금 판단 논리에 터 잡아 경영성과급이 임금에 해당하는지를 판단하고 있다. 법원은 경영성과급이 임금에 해당하는지를 판단하는 데 있어 공통으로 “경영평가성과급이 ① 계속적·정기적으로 지급되고 지급대상, 지급조건 등이 확정

27) 대법원 1990. 12. 7. 선고 90다카19647 판결.

되어 있어 ② 사용자에게 지급의무가 있다면, 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지므로 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 포함된다고 보아야 한다.”라고 보았다. 경영성과급은 특정 해에 미리 정한 ‘지급 사유 요건’을 충족하지 못하면 지급되지 않는다. 이 경우 계속적·정기적 요건도 충족시키지 못한다. 따라서 대법원은 이러한 경우에 착안하여 경영성과급의 임금성을 부정하던 게 기존 태도였다.

하지만 경영성과급의 평균임금성을 긍정하는 최근의 판결들을 살펴보면 법원의 기존 견해와는 다른 판단기준으로 삼고 있는 것처럼 보인다. 공공기관 경영성과급의 평균임금성을 긍정한 대법원 2018다 231536 판결에서 ‘지급 사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것은 임금이라고 볼 수 없’다고 판단하는 기존 견해와는 다른 해석을 했다. 해당 판결에서는 “소속 기관의 경영실적 평가결과에 따라서는 경영평가성과급을 받지 못할 수도 있”으나, “성과급이 전체 급여에서 차지하는 비중, 그 지급 실태와 평균임금 제도의 취지 등에 비추어 볼 때 근로의 대가로 지급된 임금으로 보아야 한다.”라고 판시하였다. 이를 통해 대법원이 개인 성과급에서 ‘성과급의 지급 사유 발생의 불확정성’을 임금성 판단에서 고려하지 않는 것 같이 집단 성과급에서도 동일한 기준을 확장하여 적용했다는 평가가 있다.²⁸⁾

대법원의 판단에 따라 경영성과급의 임금성을 부정하는 견해가 있다. 이 견해는 경영성과급이 필연적으로 내포하고 있는 ‘불확정성’과 ‘근로의 대상성(근로제공에 대한 직접적 또는 밀접한 관련성)’은 서로 양립할 수 없는 모순된 요소라고 말한다.²⁹⁾ 임금은 근로의 대가로 지급되어야 하는데 ‘경영성과 달성’이라는 조건이 성취되어야만 지급되는 건 임금 지급에 불확정성이 개입되므로 임금이 아니라고 보고 있

28) 심재진, “공기업 경영평가성과급의 임금성”, 「월간 노동리뷰」, 2019년 2월호, 한국노동연구원, 80면.

29) 김희성·성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼」 제35호, 노동법이론실무학회, 2022. 3, 21면.

다. 이 견해는 임금이라면 별도의 조건 성취 여부와 관계없이 근로를 제공했다면 곧바로 지급되어야 한다고 말한다. 경영성과급은 근로자의 근로제공 여부만 따지는 게 아니라 ‘경영성과 달성’이라는 조건을 성취해야 받을 수 있는 금품이기 때문에 임금성을 부정하고 있다. 즉, 경영성과급 합의에서 ‘경영성과의 달성’은 ‘정지조건’으로 보아 성과 달성이 있기 전까지는 기업의 임금 지급의무가 발생하지 않는다고 주장한다.³⁰⁾ 따라서 이 견해는 법원이 SK 하이닉스의 경영성과급을 부정한 판결의 논지에 찬성한다.³¹⁾ 판결은 ‘경영성과급 지급조건은 동종 업계의 동향, 전체 시장의 상황, 피고 회사의 영업상황이나 재무상태 등을 비롯하여 사용자의 우연하고 특수한 사정 때문에 좌우되는 요소들을 그 내용으로 삼고 있는바, 금품의 지급 여부가 근로의 제공과는 직접적인 관련이 없는 불확정적인 조건에 의존하는 경우 해당 금품을 근로의 대가라고 평가하기 어렵’다고 보아 경영성과급의 임금성을 부정한다. 해당 판결은 기존 대법원 견해와 같이 여전히 ‘지급의무의 확정성’을 근로의 대가를 판단하는 주요 지표로 보고 있다.

2) 근로의 대가 아닌 ‘특수하고 우연한 사정’에 의해 지급된다고 보는 관점

근로기준법 제2조 제1항 제5호에 따르면 임금은 ‘근로의 대가’여야 한다. ‘근로의 대가’인지 여부를 판단함에서는 금품 지급의무 발생이 근로 제공과 직접 관련되거나 밀접하게 관련된 것이어야 한다.³²⁾ 경영성과급의 임금성을 부정하는 견해는 경영성과의 달성 여부는 기업의 경영 환경을 둘러싼 여러 가지 외부 요인들에 영향을 받기 때문에 근로 제공과는 직접적인 관련이 없다고 본 것이다.³³⁾ 법원은 근로제

30) 위의 글, 11면.

31) 수원지방법원 2021. 2. 4. 선고 2020나55510 판결(대법원 상고심 계속중).

32) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94다 55934 판결.

33) 수원지방법원 2021. 2. 4. 선고 2020나55510 판결(대법원 상고심 계속중).

약이나 취업규칙, 단체협약의 정함이 있다고 하더라도 금품 지급이 개별 근로자의 ‘특수하고 우연한 사정’에 의해 좌우되는 경우엔 그 금품은 ‘근로의 대상’이 아니라고 보고 있다.

이와 같은 법원의 판단을 긍정하며 경영성과급은 기업이 근로자들에게 근로에 대한 동기 부여 및 업무를 독려하는 목적으로 지급되는 것일 뿐이고, 근로 제공에 대한 대가가 아니라는 견해가 있다.³⁴⁾ 근로자에게 경영성과급이 지급되기 위해선 기업의 경영 목표 및 소기의 실적 달성이 있어야 한다. 이 같은 달성은 시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등에 따라 좌우될 가능성이 커서 개별 근로자들의 근로 제공과는 직접적이고 밀접한 관련이 없다는 관점이다. 즉, 법원의 표현대로 경영성과급은 근로자의 근로 제공 아닌 그 밖의 ‘특수하고 우연한 사정’으로 지급되는 성질의 금품이라는 것이다. 과연 이러한 관점과 같이 노사가 경영성과급 지급기준 및 방식에 합의했고, 그 합의에 따른 목표를 달성하기 위해 협력한 결과가 ‘특수하고 우연한 사정’에 불과한가? 금품 지급의무가 근로자의 근로 제공 이외의 다른 요소들이 개입한다 해서 그 임금성을 곧바로 부정할 수 있는 논리로 나아갈 수 있는 것인가?

(3) 경영성과급을 부정하는 견해에 대한 비판

1) ‘지급 여부 확정성’ 요건에 대한 비판

과연 ‘경영성과의 달성’이 ‘정지조건’에 해당하는 것인지 의문이 든다. 해당 견해에 따르면 ‘경영성과의 달성’이라는 조건을 취득하기 이전까지 근로자는 경영성과급 배분을 주장할 수 있는 아무런 권리도 갖지 못하는 셈이다. 경영성과 달성은 주로 연간 생산목표 달성, 일정한 기준치 이상의 당기순이익 발생 등이 기준이다. 대개 이는 해당연

34) 박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총」 제49집, 한국 비교노동법학회, 2020, 199면.

도 1년간의 기업 성과를 평가해야만 측정할 수 있는 기준치이다. 당초 합의했던 목표달성 여부를 따져보기 위해서는 일정한 기간이 필요하다. 노사가 경영성과급 지급에 대한 목표를 합의하고, 그 목표달성을 위해 노무를 이행하는 기간 동안 근로자들은 경영성과급 지급에 아무런 권리를 갖지 못한다는 주장은 ‘권리’에 대한 해석을 지나치게 좁히고 있다는 생각이 든다. 경영성과급의 지급기준 및 목표설정에 합의한 이상 그때부터 이미 근로자들은 경영성과급을 청구할 수 있는 권리를 갖는다. ‘경영성과의 달성’을 정지조건으로 보고, 그 달성을 ‘우연성’으로 귀결시켜 임금성을 부정하는 것도 논리가 빈약하다. 경영성과급의 ‘지급액’ 확정은 경영 목표달성 이후지만, 경영성과급의 ‘지급조건’ 확정은 경영 목표달성 이전의 시점에서 이루어진다. 지급조건 확정만으로도 경영 목표달성이 ‘우연성’에 기초하지 않는다고 생각한다. ‘일정한 목표치를 넘는 경영실적 달성 시 성과급을 지급한다.’라는 합의가 있는 이상 기업의 임금 지급의무가 확정되었다고 해석하는 것이 옳다.

법원이 보는 사용자 지급의무, 즉 ‘지급 여부 확정성’은 지급의무 성립 이전 단계에 관한 판단 시점과 지급의무가 성립된 이후 단계에 관한 판단 시점을 오인하고 있다는 견해가 있다.³⁵⁾ 이 견해에 따르면 단체협약 등 노사합의에 따라 경영성과급 지급 여부는 이미 확정된 것이다. 하지만 법원은 경영성과급이 지급되는 시점에서 ‘경영성과급 지급의 불확정성’을 말한다. 이에 따라 임금성을 부정하는 것은 선후 관계를 제대로 파악하지 못한 법원의 착오라고 보는 것이다. 이 같은 관점을 인용하여 서울중앙지방 2019가합538253 판결에서도 “해마다 노사합의나 내부결재 등을 통하여 미리 경영성과급 지급기준을 정하고, 해당 사업연도의 결산이 끝나고 당기순이익이 확정되면 그 지급기준에 따라 산정된 경영성과급을 지급하였던 것인 이상, 미리 정하

35) 권오성, “경영성과급의 임금성”, 「월간 노동법률」, 2020년 3월호, (주)중앙경제, 67면.

여진 지급기준에 맞는 경영실적을 달성하였다면 피고로서도 그 실적에 따른 경영성과급의 지급을 거절할 수 없었을 것”이라고 판단하였다. 따라서 해당 판결에서는 경영성과급은 노사합의로 미리 정해진 것이므로 ‘지급 여부의 확정성’을 인정했다고 볼 수 있다.

‘지급 여부의 확정성’을 기준으로 평균임금 판단기준으로 삼는다는 게 적절하지 않다는 견해도 있다. 이 견해는 지급 여부나 지급액이 사전에 확정되어야 하는 사정은 통상임금에서는 중요할 테지만, 지급된 금액을 사후적으로 산정하는 평균임금 요건으로는 적절하지 않다는 것이다.³⁶⁾ 법원이 통상임금 판단기준과 평균임금 판단기준을 혼동하여 적용하고 있다는 관점이다. 서울중앙지법 2019가합54535 판결에서도 경영성과급을 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고, 휴직자 및 정직자에게는 지급되지 않는 것은 ‘고정성’을 갖추지 못한 경우로 볼 수 있으나 “고정성은 ‘통상임금’의 요소이지 ‘임금’의 요소가 아니므로, 위와 같은 재직자 요건의 존재를 들어 이 사건 각 인센티브가 근로의 대가 즉 임금에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다.”라고 판시하면서 경영성과급의 평균임금성을 긍정하였다. 고정성 요건을 통상임금 판단기준으로 삼을 수 있는지는 별론으로 하고, 최근 판결에서는 통상임금의 판단기준과 평균임금의 판단기준을 명확히 분리해야 한다는 점을 명시하고 있다.

경영성과급이 임금에 해당하려면 ‘계속적·정기적’으로 지급될 것을 필요로 하는 것에 대한 비판도 있다. 경영성과급의 임금성을 판단하기 위해서 가장 일차적으로 고려되어야 하는 기준은 ‘근로의 대가성’이고, 계속적·정기적 지급 및 사용자 지급의무는 이를 판단하기 위한 지표에 불과하다고 보는 견해이다.³⁷⁾ 이처럼 대법원이 ‘근로의 대가성’ 이외에도 지급 방식에 따른 추가적인 지표를 두는 까닭은 은혜적 혹은 복리

36) 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「월간노동법률」, 2019년 12월호, (주)중앙경제, 30면.

37) 위의 글, 32면.

후생적 명칭의 급부가 임금성이 있는지를 판단할 때 계속적·정기적으로 지급되었는지, 단체협약 등에서 정하는 사용자 지급의무가 있는지를 따져서 판단했던 것이 경영성과급의 판단기준에 그대로 적용되었다고 해석하는 관점도 있다.³⁸⁾ 이 견해 역시 근로의 대가로 지급되는 급부가 분명할 경우, 그 급부가 계속적·정기적으로 지급되거나 사용자 지급의무가 있는지는 추가로 고려해야 하는 지표는 아니라고 말한다.

법원도 현대해상화재보험 경영성과급을 긍정한 사례³⁹⁾에서 “피고가 해마다 노사합의나 내부결재 등을 통하여 미리 경영성과급 지급기준을 정하고, 해당 사업연도의 결산이 끝나고도 당기순이익이 확정되면 그 지급기준에 따라 산정된 경영성과급을 지급하였던 것인 이상, 미리 정하여진 지급기준에 맞는 경영실적을 달성하였다면 피고로서도 그 실적에 따른 경영성과급의 지급을 거절할 수 없을 것으로 보이고, 실제로도 피고는 매년 당기순이익이 미리 정하여진 지급기준에 해당하면 그에 따른 경영성과급을 예외 없이 지급하여 왔으므로, 이를 은혜적인 급부라고 보기 어렵다.”라고 판시하였다.

그동안 판례는 ‘지급의 확정성’을 엄격하게 해석하여 경영성과급의 임금성을 부정해왔다. 하지만 경영성과급을 둘러싼 법적 분쟁의 주된 이유는 퇴직금 산정 기초가 되는 평균임금 문제이다. 평균임금은 임금을 지급하고 사후적으로 평가하는 성질을 갖는다. 평균임금성을 다투는 논의에서 ‘사전확정성’을 법으로 정하고 있는 통상임금의 요건처럼 엄격한 의미로 해석해야 할 근거는 없다.

2) 경영성과급이 ‘특수하고 우연한 사정’으로 지급된다는 견해 비판
그렇다면 경영성과급은 ‘특수하고 우연한 사정’으로 인해 근로의

38) 심재진, “공기업 경영평가성과급의 임금성”, 「월간 노동리뷰」, 2019년 2월호, 한국노동연구원, 81면.

39) 서울중앙지방법원 2021. 4. 15. 선고 2019가합538253 판결(항소심 계속 중).

대가가 아닌 은혜적으로 지급되는 금품에 불과한가? 이를 판단하기 위해 그동안 법원이 경영성과급 임금성 판단기준 이외 ‘특수하고 우연한 사정’이라는 지표를 어떻게 판단 해왔는지 판례를 통해 살펴보고자 한다.

‘특수하고 우연한 사정’에 따라 좌우되어 임금성을 인정하지 않는 대표적 사례로 ‘실비변상적 성격의 금품’을 들 수 있다. 대법원 1999. 2. 9. 선고 97다56235 판결에서 법원은 근로자가 집행 업무를 수행할 때마다 사용자가 집행 의뢰인으로부터 받은 수수료를 그때그때 지급한 노무비는 실비변상적 성격을 갖는 금품으로써 임금성을 부정하였다. 판례를 살펴보면 “사용자 이외의 자가 지급한 금품이나 근로의 대상으로서 지급되는 것이 아니라 근로자가 특수한 근무조건이나 환경에서 직무를 수행함으로 말미암아 추가로 소요되는 비용을 변상하기 위하여 지급되는 실비변상적 금원 또는 사용자가 지급의무 없이 은혜적으로 지급하는 금원 등은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함되지 아니한다.”라고 판시하고 있다. 이후 이 판례를 인용한 다른 판결⁴⁰⁾에서는 금품이 실비변상적인 성격을 갖는 경우를 ‘개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 때’라고 판시하였다.

대법원 1995. 5. 12 선고 94다55934판결에서 법원은 회사가 임원과 부장 중 자기 차량을 보유한 운전자들만 직급별로 차등 지급한 자가 운전보조비의 임금성을 부정하였다. 판례를 살펴보면 “위 자가운전보조비는 단순히 직급에 따라 일률적으로 지급된 것이 아니고 그 지급여부가 근로 제공과 직접 또는 밀접하게 관련됨이 없이 오로지 일정 직급 이상의 직원이 자기 차량을 보유하여 운전하고 있는지 여부라는 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 따라 좌우되는 것”이라 임금

40) 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003다10650판결, 대법원 2006. 8. 24. 선고 2004다35052 판결.

성을 인정할 수 없다고 판시하였다.

법원은 근로자 개인 실적에 따라 지급되는 성과급의 경우 시간이 지남에 따라 그 판단을 달리하고 있다. 종전의 판례는 개인 실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성을 부정했다. 개인 성과급도 경영성과급과 마찬가지로 ‘특수하고 우연한 사정’에 따라 좌우되는 임금이기 때문에 근로의 대가가 아니라고 본 것이다. 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결은 회사가 영업직원에게 지급하는 성과급의 임금성을 부정하였다. 판례를 살펴보면, “피고 회사가 영업직원에게 지급하는 이 사건 성과급은 근로자 개인의 실적에 따라 그 지급 여부와 지급 액수가 결정되는 것인바, 근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과급은 지급조건과 지급 시기가 단체협약 등에 정하여져 있다고 하더라도 지급조건 충족 여부는 근로자 개인의 실적에 따라 달라지는 것으로서 근로자의 근로제공 자체의 대상이라고 볼 수 없으므로 임금에 해당된다 할 수 없다.”고 판시하였다.

하지만 법원은 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결에서 기존 태도와는 달리 영업사원의 인센티브의 임금성을 긍정한다. 판례를 살펴보면, “피고 회사가 인센티브(성과급) 지급규정이나 영업 프로모션 등으로 정한 지급기준과 지급시기에 따라 인센티브(성과급)를 지급하여 왔고, 차량판매는 피고 회사의 주업으로서 영업사원들이 차량판매를 위하여 하는 영업활동은 피고 회사에 대하여 제공하는 근로의 일부라 볼 수 있어 인센티브(성과급)는 근로의 대가로 지급되는 것이라고 보아야 하며, 매월 정기적, 계속적으로 이루어지는 인센티브의 지급이 개인근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 우발적, 일시적 급여라고 할 수 없고, 지급기준 등의 요건에 맞는 실적을 달성하였다면 피고 회사로서는 그 실적에 따른 인센티브의 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적인 급부라고 할 수도 없다”고 판시하였다. 즉, 기존 법원은 개인의 영업 실적 달성을 ‘특수하고 우연한 사정’이라고 보았으나 현재는 개인 실적에 따른 인센티브의 근로

의 대가성을 인정하였다. 따라서 개인의 실적 달성은 ‘특수하고 우연한 사정’에서 제외된다고 봄이 타당하다.

그동안의 판결들로 미루어 봤을 때, 법원이 판단하고 있는 ‘특수하고 우연한 사정’이란 ① 근로자가 특수한 근무조건에서 근로를 이행하기 위해 비용이 발생하는 경우 ② 근로 제공과는 무관한 개별 근로자의 특수한 상황 및 자격을 충족할 때 금품을 지급하는 경우 ③ 금품 지급의무가 현시점에서는 불분명한 개인의 실적 등에 달린 경우이다. 이 중 ③의 경우는 그 이후의 판결에 따라 ‘특수하고 우연한 사정’에서 제외되었다. 즉, 법원은 근로자가 완전한 근로 제공을 위해 그에 수반되는 비용을 사용자로부터 받는 경우, 그리고 근로 제공과는 무관한 사정 때문에 금품을 받는 경우 정도를 ‘특수하고 우연한 사정’이라고 보는 것이다. 이와 같은 판단들에 비추어 볼 때, 제반 경영 상황을 둘러싼 외부 요인들이 목표달성 여부에 개입한다고 하더라도 노사가 합의하여 경영성과에 대한 목표를 정하고, 연간 목표 달성하기 위해 근로자들이 협력하여 근로를 이행했다면, 목표달성으로 지급되는 경영성과금이 곧바로 ‘특수하고 우연한 사정’으로 해석될 수는 없다고 생각한다.

(4) 평균임금 법리에 터 잡아 임금성을 판단하는 관점의 문제점

그동안 대법원은 경영성과금이 ① 계속적·정기적으로 지급되고 ② 사용자의 지급의무가 있으면 ‘평균임금’이 아닌 ‘근로의 대가’에 해당한다고 보았다. 평균임금 법리에 터 잡아 경영성과금의 ‘평균임금성’을 판단한 게 아니라 ‘임금성’을 평가한 것이다. 이와 같은 판단은 경영성과금의 근로기준법상 임금성을 부정할 수 있는 여지를 제공하였다고 본다.

경영성과금의 임금성을 평균임금 법리에 근거하여 판단하는 것을 재고해야 할 시점이 왔다고 생각한다. 평균임금은 퇴직금 산정을 위

한 도구적 개념일 뿐이다. 경영성과급은 노사가 성과급 지급기준을 합의했을 때부터 이미 ‘확정성’을 갖는다. 그 후 성과급 지급조건이 달성되었다면, 그것은 ‘특수하고 우연한 사정’이 아니라 ‘미리 합의된 목표의 실현’이다. 따라서 경영성과급은 우발적인 사유로 인해 지급되는 성질이 아니므로 임금성이 부정될 수 없다. 현재 법원은 여전히 경영성과급을 평균임금 틀에서 해석하며 임금성을 판단한다. 경영성과급이 계속적·정기적으로 지급되었는지 등 그동안 임금의 지급행태를 따져 임금성을 판단하는 방식이 아니라 경영성과급 자체가 ‘근로의 대가성’을 갖는가를 직접 검토할 필요가 있다.

V. 결론

그동안 대법원은 근로기준법 시행령 제6조에서 정하는 정기적·일률적 요건뿐 아니라 ‘고정성’ 요건을 추가하여 통상임금 판단기준으로 삼았다. 법문에 없는 추가적 요건은 근로자가 받는 보수 중 일부를 통상임금에서 배제하는 결과를 낳았다. 대표적인 예로 재직 조건이 붙은 정기상여금이 있다. 대법원은 재직 조건이 붙은 정기상여금이 통상임금 요건 중 고정성을 결한다고 판단하였다. 따라서 대법원은 정기상여금의 통상임금성을 부정해온 입장이다. 최근 하급심에서 재직 조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 긍정하는 판결들이 잇따라 나오고 있다. 하지만 하급심 판단도 여전히 ‘고정성’ 요건 토대 위에서 재직 조건이 부가된 정기상여금의 통상임금성을 판단하고 있다. 이런 판단은 임금 지급 방식에 따라 통상임금 요건을 결정한다. 결국, 사용자에게 통상임금 판단을 맡기게 되는 결과를 초래한다. 따라서 통상임금 ‘고정성’ 요건을 재정립할 필요성이 대두된다. ‘일률성’은 소정근로시간과 그에 따른 급여로부터 도출되는 일정한 비율이란 뜻으로 해석되어야 한다. ‘고정성’은 임금 지급 방식에 따라 통상임금성을

판단하게 되는 위험이 존재하므로 법원이 말하는 ‘고정성’ 요건은 통상임금 판단기준에서 제외할 필요가 있다.

근로기준법 제47조는 도급근로자에 관한 규정을 두고 있다. 최근 대법원이 정수기 수리기사들이 근로기준법상 도급근로자에 해당하기 때문에 이들이 받은 수수료는 통상임금에 해당한다고 판시하였다. 이러한 판결로 인해 거의 논의 되지 않았던 ‘도급근로자’에 대한 관심도 높아지고 있다. 건당 수수료를 받는 플랫폼 노동자도 근로기준법 제47조 ‘도급근로자’ 개념에 포섭하여 시간당 임금을 산정하여 이들의 임금 수준을 보호해야 한다는 주장도 있다. 근로기준법상의 도급근로자는 소정근로시간이 정해진 것을 전제로 한다. 소정근로시간의 정함이 없는 플랫폼 노동자의 경우, 현행 법제 하에서는 정수기 수리·설치 기사들처럼 근로시간에 기반한 통상임금을 구할 방식이나 실익이 없다. 또한, 소정근로시간의 정함이 없는 플랫폼 노동자들의 보수 수준 유지 방안은 근로기준법상 ‘도급근로자’와 다른 틀에서 논의되어야 한다.

대법원은 매년 경영실적에 따라 지급되는 경영성과급에 대해 ‘계속적·정기적으로 지급’되고, ‘사용자의 지급의무’가 있으면 ‘근로의 대가’에 해당한다고 보았다. 이런 판단기준은 평균임금 법리에 터 잡아 경영성과급의 ‘임금성’을 평가한 것으로 해석할 수 있다. 경영성과급을 둘러싼 논의가 주로 퇴직금 분쟁인 것을 고려한 판단기준이라고 생각된다. 이러한 기준에 대해 ‘지급여부 확정성’은 통상임금의 요건인 것이지, 평균임금 판단기준으로 삼는다는 것이 적절하지 않다는 비판이 있다. ‘계속적·정기적 지급’ 역시 지급 방식에 따라서 근로의 대가성을 판단하고 있다는 점에서 비판을 받는다. 최근 하급심에서는 경영성과급의 평균임금성에 대해 엇갈린 판결들이 나오고 있다. 그러나 경영성과급의 임금성을 긍정하는 판결들도 평균임금 법리에서 벗어나지 못한 채 경영성과급의 임금성을 판단하고 있다. 경영성과급이 계속적·정기적으로 지급되었는지 등 그간 지급형태를 따져 임금성을

판단하는 게 아닌 경영성과급 자체가 근로의 대가성을 가지고 있는지 검토할 필요가 있다.

주제어: 임금, 통상임금, 정기상여금, 도급근로자, 평균임금

【참고문헌】

김유성, 노동법 I, 법문사, 2005.

임종률, 노동법(제20판), 박영사, 2022.

하경효, 임금법제론, 신조사, 2013.

권오성, “주휴수당의 딜레마-초단시간근로자의 최저임금 차별 문제를 중심으로-”, 「사회법연구」 제35호, 한국사회법학회, 2018.

권오성, “‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성”, 「중앙법학」 제20집 제2호, 중앙법학회, 2018.

권오성, “경영 성과급의 임금성”, 「월간노동법률(제346호)」, (주)중앙경제, 2020.

권오성, “플랫폼 노동자 최저보수 보장방안”, 「플랫폼 노동자 적정소득 보장방안 공개토론회 자료집」, 한국노동사회연구소, 2022.

권혁, “통상임금의 ‘고정성’에 관한 법리 재평가”, 「노동법논총」 제28집, 한국비교노동법학회, 2013.

김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 「노동법학」 제71호, 한국노동법학회, 2019.

김희성·성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼」 제35호, 노동법이론실무학회, 2022.

박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총」 제49집, 한국비교노동법학회, 2020.

방강수, “통상임금 법리의 이원화”, 「법학논총」 제36권제4호, 한양대학교법학연구소, 2019.

방강수, “도급제 임금에서의 통상임금 법리”, 「노동법연구」 제51호, 서울대학교노동법연구회, 2021.

- 심재진, “공기업 경영평가성과급의 임금성”, 「월간노동리뷰(제167호)」, 한국노동연구원, 2019.
- 유성재, “지급일 재직요건의 효력과 통상임금성”, 「노동법포럼」 제27집, 노동법이론실무학회, 2019.
- 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「월간노동법률(제343호)」, (주)중앙경제, 2019.
- 이철수, “통상임금에 관한 최근 판결의 동향과 쟁점 - 고정성의 딜레마-”, 「서울대학교법학」 제54집제3호, 서울대학교 법학연구소, 2013.
- 임상민, “재직 조건부 정기상여금의 통상 임금성”, 「노동법연구」 제51호, 서울대학교노동법연구회, 2021.

[Abstract]

A Review of Recent Court Rulings on Wages

Lee Saethyul · Kwon, Ohseong***

This paper defines the concept of wages through the latest judgment review.

First, this article examines the fixedness standard of ordinary wages. Until now, the Supreme Court has determined that regular bonuses with ‘incumbent condition’ added are not ordinary wages. This is because it does not meet the fixedness standard of ordinary wages. This paper examines whether there are any problems with these Supreme Court arguments.

Second, this article examines the concept of “contract workers” and the minimum wage protection measure for platform workers. This paper reviews the definition of contract workers under the Labor Standards Act through recent precedents as well as how to guarantee the minimum wage of workers whose working hours are not predetermined.

Lastly, this article examines whether performance bonus can be considered average wages. Until now, the Supreme Court has judged that performance bonuses are not average wages. However, the recent lower court ruling has overturned the Supreme Court’s judgement. This paper reviews whether the performance-based bonus provided to workers

* Graduate Student, Sungshin Women’s University College of Law

** Professor, Sungshin Women’s University College of Law

according to the company's performance can be considered to be wages under the Labor Standards Act. The Supreme Court has judged performance bonus based on the legal ground of average wage law. This article examines whether there is any problem with such judgement of the Supreme Court.

Key word: Wages, Regular Rate of payment, Regular Bonus, Contract Workers, Average Wages